

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5035574-96.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: JOSE WENCESLAU ALCANTARA FERNANDES

ADVOGADO(A): THIAGO ALEXANDRE FADINI (OAB ES015090)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER O RECURSO COMO MEDIDA DE URGÊNCIA E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, para atribuir efeitos suspensivos à decisão de evento 9 da ação n. 5030010-39.2024.4.02.5001, ratificando-se a tutela provisória de urgência concedida (evento 3, DESPADEC1). Intimem-se. Preclusa a decisão, dê-se baixa dos autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de dezembro de 2024.

5035574-96.2024.4.02.5001

500003475274 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5035574-96.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: JOSE WENCESLAU ALCANTARA FERNANDES

RELATÓRIO

UNIÃO interpôs o presente recurso como **medida de urgência** contra a decisão proferida na ação n. 5030010-39.2024.4.02.5001 (autos principais), em trâmite no Juízo Federal do 2º Juizado Especial de Vitória, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que a União implemente o aumento de 50% (Resolução CNJ 500/2023), referentes ao auxílio-saúde (Resolução CNJ 294/2019), no prazo de 30 dias.

Em suas razões, alega, em síntese, que a Medida Provisória n.º 1.570, de 26 de março de 1997, convertida na Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, amplia a aplicação das Leis n.º 4.348/1964, 5.021/1966 e 8.437/1992, vedando expressamente o deferimento de tutela antecipada contra a Fazenda Pública que implique concessão de benefícios a servidores públicos e, via de consequência, a seus descendentes, bem como em relação a decisões judiciais que esgotem, no todo ou em parte, o objeto das ações. Sustenta que, considerando o pedido formulado pela parte demandante, não pode a decisão judicial impor à União seu imediato cumprimento, com base em cognição sumária, se a própria sentença, fundada em cognição exauriente, deve aguardar o trânsito em julgado. Ressalta que todos os atos previstos no art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997 exsurtem como verdadeiras obrigações de fazer que, por acarretarem indissociáveis efeitos pecuniários de trato sucessivo, fogem à regra geral que autoriza a execução provisória, impedindo, pela mesma lógica, a antecipação dos efeitos da tutela e seu imediato acatamento quando condenada a Fazenda Pública. Argumenta que tal vedação, por certo, visa resguardar o Erário, não ocasionando prejuízo irreparável à parte autora, pois que esta, mesmo com a readequação empreendida em sua estrutura remuneratória, detém meios suficientes para arcar com sua sobrevivência, ficando garantido o pagamento retroativo, corrigido e acrescido de juros de mora, caso ao final venha a sair vencedora. Aduz que, na hipótese dos autos, está presente o chamado *periculum in mora inverso*, vez que, por se tratar de verba alimentar, é a União que dificilmente conseguirá reaver os valores entregues à parte recorrida em virtude da propalada irrepetibilidade das parcelas vindicadas, destacando que, por outro lado, no momento em que há norma processual que veda a execução provisória de sentença que importe uma das situações acima, perfeitamente enquadráveis nos presentes autos, conclui-se, necessariamente, que sua execução, revestida de tutela antecipatória também restará vedada.

Foram formalizados os seguintes pedidos ao final:

"Por todo o exposto, diante da ausência de pressupostos processuais e dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela questionada, bem como da impossibilidade de imediato cumprimento da ordem, antes do trânsito em julgado, pugna a União seja recebido o presente recurso com efeito suspensivo e, ao final, seja ele provido, cassando-se a antecipação dos efeitos da tutela que determinou o pagamento de auxílio-saúde em franco descompasso com o ordenamento jurídico vigente."

Decisão de evento 3, DESPADEC1 deferindo a liminar requerida.

VOTO

A decisão de evento 3, DESPADEC1 concedeu a medida liminar sob os seguintes fundamentos:

"Não há dúvidas a respeito da possibilidade de o juiz conceder tutelas provisórias de urgências no microsistema dos juizados especiais federais. A questão foi definitivamente consolidada com o advento da Lei n. 10.259/2001, que permitiu, em seu art. 4º, ao juiz conceder "medidas cautelares no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação". A Lei n. 12.153/2009, por sua vez, em seu art. 3º, além da cautelar, estabelece a possibilidade de antecipação dos efeitos da sentença de mérito: "O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação".

Como tais decisões provocam lesões materiais e processuais às partes, muitas vezes graves, o sistema expressamente possibilitou recurso no art. 5º da Lei 10.259/2001 e no art. 4º da Lei 12.153/2009. Ressalta-se que esta Turma Recursal denominou esse meio de impugnação de decisão judicial de "Recurso de Urgência" ou "Medida de Urgência".

A parte autora, servidor pública federal, ajuizou a ação de que esta medida liminar é dependente objetivando a aplicação da Resolução CNJ 294/2019, com as alterações levadas a efeitos pela Resolução CNJ 500/2023, referente ao auxílio-saúde. Este foi o pedido formulado na inicial da demanda:

" i. Seja declarado/reconhecido o direito do autor, ao recebimento do auxílio saúde indenizatório e em pecúnia, na forma do art. 4º, IV da Resolução CNJ nº 294/2019 c/c art. 6º e art. 196, ambos da CRFB/1988 c/c art. 230 da lei nº 8.112/1990, e nos termos em que fundamentado; ii. Seja a União condenada a obrigação de fazer, consistente na implementação e pagamento do auxílio saúde indenizatório ao Autor, sempre considerando cônjuge, dependentes/filhos, nos termos da Resolução CNJ nº 294/2019 (em especial o art. 5º, §§2º, 4º, 5º, inciso II, 6º), e em que fundamentado; iii. Seja a União condenada ao pagamento de indenização por Danos Materiais ao Autor, no valor de R\$ 13.170,92 (treze mil, Página 11 de 11 cento e setenta reais e noventa e dois centavos), quantificados de 05/2023 até 08/2024, e por ser uma obrigação de trato sucessivo, SEM prejuízo a condenação da União ao pagamento dos valores vincendos, a ser apurado em cumprimento de sentença, tudo com juros e correção monetária na forma determinada pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal (ou seja, SELIC, na forma do Art. 3º da EC nº 113/2021), e nos termos em que fundamentado."

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que a União implementasse o aumento de 50% (Resolução CNJ 500/2023), referente ao auxílio-saúde (Resolução CNJ 249/2019), no prazo de 30 dias, sob os seguintes fundamentos:

"A parte autora, servidor pública federal, requer a aplicação da Resolução CNJ 294/19, com as alterações levadas a efeitos pela Resolução CNJ 500/23, referente ao auxílio saúde. Há pedido de obrigação de pagar e obrigação de fazer. O pedido referente à obrigação de pagar será analisado apenas em sede de cognição exauriente. Por sua vez, no que se refere à obrigação de fazer, há pedido de tutela provisória, tanto na modalidade tutela de urgência (art. 300 do CPC), quanto na modalidade tutela de evidência (art. 311 do CPC). A União foi intimada previamente para se manifestar sobre as tutelas provisórias, tendo apresentado manifestação apenas quanto à tutela de urgência, nada mencionado quanto à tutela de evidência.

Creio não haver dúvidas sobre o direito em si. A parte autora faz jus ao auxílio saúde (art. 4º, IV da Resolução CNJ 294/19). Não havia previsão de limite mínimo, mas apenas de limite máximo (10% do subsídio). E mais. Com a edição da Resolução 500/23 foi fixado aumento de 50% no valor a ser pago, para os magistrados e servidores com mais de 50 anos ou com doenças graves.

Passo, agora, a analisar a partir de que momento o aumento de 50% (Resolução CNJ 500/23) deveriam ser implementados (sem análise, nesse momento, ao direito de eventuais atrasados). Senão vejamos.

A Resolução CNJ 500/23 (aumento de 50%) foi publicada em 29.05.2023 e fixou em seu art. 2º que "Os Tribunais deverão promover a necessária recomposição orçamentária para a implementação do disposto no presente ato até o final do exercício financeiro seguinte ao da publicação desta Resolução". A Resolução em tela nada mencionou sobre a implementação do benefício, mas fixou prazo até o final de 2024 para a recomposição orçamentária correspondente.

Para execução plena da Resolução, há dois marcos temporais sensíveis que precisam ser explicitados: implementação financeira e recomposição orçamentária. Na Resolução CNJ 500/23 (aumento de 50%) nada foi mencionado sobre a implementação, mas foi fixado prazo para a recomposição orçamentária. Há, portanto, lacuna a ser suprida acerca do momento da implementação financeira. Dessa forma, com base na analogia, creio que deva utilizar os parâmetros temporais da Resolução CNJ 495/23, ato normativo de mesma natureza que estipulou o piso observado para efeito de reembolso do auxílio saúde.

Registro que a implementação da Resolução CNJ 495/23 (piso de 8%) deva ocorrer no início de 2024 e não no final de tal exercício. Nada impede que a implementação seja efetivada no final do exercício. Mas a falta de regra explícita quanto à data de implementação, indica que a mesma deva ocorrer no início do exercício financeiro. E assim afirmo com base no princípio da anualidade na esfera financeira (art. 34 da Lei 4.320/64).

Assim, a implementação da Resolução CNJ 500/23 (aumento de 50%) deve ocorrer no início do exercício de 2024 por analogia aos parâmetros temporais estipulados na Resolução CNJ 495/23.

Por sua vez, a recomposição orçamentária da Resolução CNJ 500/23 deve ocorrer até o final do exercício de 2024. Importante registrar que a execução orçamentária e a execução financeira, embora atreladas, não se confundem, podendo ocorrer em marcos temporais diversos do mesmo exercício, em função da peculiaridade do tema (Lei 4.320/64).

Estabelecida a interpretação acima, sobre aos marcos temporais da Resolução CNJ 500/23, estou convencido de que a União não se encontra em mora. Pelo menos não ainda. Explico. Mesmo que se venha a reconhecer o implemento das condições com a vigência dos Atos do CNJ (e eventual direito a atrasados), o benefício em tela só é exigível financeiramente a partir do primeiro pagamento do exercício seguinte à edição das Resoluções, ou seja, em 2024. Assim, apenas se não houver pagamento do auxílio saúde com os valores reajustados (aumento de 50% para maiores de 50 anos), a partir do dia 20.01.2024 (data de pagamento da magistratura Federal) é que ocorrerá mora da União.

Seja como for, constatei que a União não impugnou objetivamente o direito ao benefício. E talvez nem pudesse. Afinal, o benefício foi criado pelo CNJ, que é órgão de controle da própria União, em relação ao Judiciário. Seria um paradoxo a União discordar dela própria. Não obstante, a União também não apresentou, em sua manifestação, nenhuma informação sobre a data da efetiva implementação dos benefícios aqui analisados. E tal informação seria exigível com base no princípio do planejamento (art. 174 da CR/88). Parece-me razoável, portanto, considerar que o pleno exercício do direito em tela ainda não se encontra incontroverso, sob a ótica da implementação financeira. Logo, há risco de dano, sendo prudente a intervenção do Judiciário, a teor do inciso XXXV do art. 5º da CR/88.

A matéria também me parece sensível, eis que abarca garantia à saúde dos servidores, em especial aqueles com mais de 50 anos. E a qualidade de saúde dos membros do Judiciário impacta diretamente na qualidade da prestação jurisdicional, enquanto efetividade e eficiência do exercício de um dos poderes da República. Há, portanto, interesse público difuso no sentido de que os servidores tenham sua saúde controlada, para bem exercer suas atribuições constitucionais. Por fim, não há risco de irreversibilidade, pois a autora, na qualidade de servidora pública federal, é solvente."

Com efeito, o art. 1º da Lei n. 9.494/1997 estabeleceu a impossibilidade de concessão da tutela antecipada contra a Fazenda Pública que objetive reclassificação, equiparação, aumentos ou extensão de vantagens pecuniárias a servidores públicos, bem como lhes conceder pagamento de vencimentos. De igual modo a Lei Federal n. 8.437/1992 dispõe em seu art. 1º, § 3º, que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC n. 4/DF, firmou entendimento pela constitucionalidade dos dispositivos da Lei n. 9.494/1997, que excluiu, taxativamente, hipóteses de antecipação de tutela contra o Poder Público: a) reclassificação ou equiparação de servidores públicos; b) concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; c) outorga ou acréscimo de vencimentos; d) pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou e) esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas.

Dessa forma, embora haja probabilidade acerca do direito da parte recorrida, ante a documentação jungida aos autos, sua concessão em sede de antecipação de tutela, encontra óbice na Lei 9.494/1997.

Como bem destacou a parte recorrente, é notório o *periculum in mora inverso*, devido ao rígido modelo de concessão de medidas liminares em face do Poder Público, previsto nas Leis n.º 9.494/1997 e 8.437/1992.

Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para atribuir efeitos suspensivos à decisão agravada (evento 9 da ação 5030010-39.2024.4.02.5001). Intimem-se e, após o decurso do prazo para contrarrazões, voltem os autos conclusos."

Desnecessário reiterar os fundamentos da decisão supracitada, os quais serão tomados como razões de decidir para atribuir efeitos suspensivos à decisão de evento 9 da ação n. **5030010-39.2024.4.02.5001**, ratificando-se a tutela provisória de urgência concedida.

A Lei 9.099/1995, em seu art. 55, determina que só haverá condenação em honorários advocatícios no segundo grau se a parte recorrente for vencida na sua insurgência, ou seja, após a sentença, em casos de interposição de recurso nominado.

Dispositivo

VOTO POR CONHECER O RECURSO COMO MEDIDA DE URGÊNCIA E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, para atribuir efeitos suspensivos à decisão de evento 9 da ação n. **5030010-39.2024.4.02.5001**, ratificando-se a tutela provisória de urgência concedida (evento 3, DESPADEC1). Intimem-se. Preclusa a decisão, dê-se baixa dos autos.

